Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
5ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

ROD BR-101 SUL KM 80, S/N, - do km 86,007 ao km 88,000, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54345-160 - F:(81) 34615600

Processo nº 0020193-02.2020.8.17.2810

AUTOR: ANNA CAROLINA CALHEIROS D ALMEIDA

REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ANA CAROLINA CALHEIROS D'ALMEIDA RIBEIRO em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Relata, em síntese, que é portadora de Retocolite Ulcerativa-RCUI, doença inflamatória intestinal e que desde 2004 iniciou tratamento com diversos medicamentos, mas não obteve êxito, tendo, inclusive, pioras severas da doença.

Aduz que solicitou à demandada o fornecimento de tratamento médico requisitado pelo Dr. Carlos Brito, profissional que acompanha a autora há anos. Ocorre que a Ré, de forma abusiva, negou o tratamento médico, conforme resposta em Protocolo nº 33967920200622424484.

Informa que, desde MAIO/2020, não faz tratamento para a doença ao qual é portadora, tendo utilizado corticoide em doze máxima para atenuar os sintomas da doença e que o tratamento médico com a medicação tofacitinibe (Xeljanz®) é a única opção de tratamento para a Autora no momento, em virtude de ter mecanismo de ação diferente dos demais tratamentos já utilizados. Pugnou pela concessão de tutela de urgência. No mérito, requereu a confirmação da decisão de concessão do pedido de urgência, juntou procuração e documentos. Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Tutela de urgência deferida. A parte ré agravou da decisão. Em sede de interlocutória, o Relator concedeu efeito suspensivo à decisão atacada (ID 71254620 - Pág. 4).

Devidamente citado, o demandado ofereceu contestação na qual alegou, em síntese, que: I) a negativa decorreu de exclusão de cobertura contratual; II) em razão de a autora não estar internado, o medicamento foi caracterizado como de uso domiciliar, pelo que não se torna possível autorização. Por essa razão, não há se falar em ilegalidade na conduta da demandada; III) o medicamento está fora do Rol da ANS e, portanto, excluído da cobertura contratual; IV) não houve ato ilícito e, portanto, inexiste dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos aduzidos na exordial. Juntou procuração e documentos.

Posteriormente, o Des. Relator, em sede de Agravo Interno, reconsiderou a decisão de suspensão dos efeitos da tutela concedida em 1º grau e deu provimento ao referido Agravo, determinando o fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente.

Houve réplica e juntada de documentos.

Devidamente intimadas, as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas.

Os autos vieram conclusos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, sucinto.

Passo a decidir.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora pugna pelo fornecimento de medicamento, sob a alegação da necessidade urgente, conforme laudo médico.

Há prova nos autos que demonstram o vínculo contratual entre as partes, consoante se conclui pela análise do documento de ID's 69308729 - Pág. 1 e 2. A parte autora comprovou a necessidade do tratamento através de uso de medicamento, conforme prescrição médica, constante nos autos (ID 69308723 - Pág. 1).

A demandada alegou, em linhas gerais, que o Contrato de Seguro Saúde em que se funda a presente demanda é regido por cláusulas que limitam e especificam os riscos cobertos e quantidade de sessões, de modo que a negativa se dá por questões contratuais e previsão da ANS.

O cerne da controvérsia, portanto, diz respeito à legalidade da recusa à realização do tratamento vindicado (fornecimento de medicamento) o qual a parte autora, em virtude de indicação médica, pleiteou junto à demandada.

Antes de qualquer coisa, vale dizer que a relação jurídica existente entre as partes subsume-se a legislação protetiva de defesa do consumidor, sendo oportuno ressaltar que o CDC, inspirado na Carta Magna traz em suas normas elemento axiológico, consistente na defesa do consumidor, erigida na Constituição Federal como direito fundamental (art. 5º, XXXII).

Em reforço à tese de incidência do CDC no caso concreto, está a Súmula 608 do STJ a qual preconiza que:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

Nesse diapasão, o contrato firmado entre as partes deve estar em total observância às regras previstas no Código Protetivo, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.

Conforme sobredito, a parte ré, em linhas gerais, fundou a negativa do tratamento em razão de expressa vedação contratual e limitações das diretrizes da ANS.

Quanto à vedação/limitação contratual alegada pelo réu, é sabido que as cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito, a teor do artigo 51, IV do CDC.

Ademais, não se afigura lógico o contrato garantir a cobertura de tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos beneficiários e, ao mesmo tempo, negar o fornecimento do procedimento prescrito por profissional habilitado, que certamente analisou o caso do paciente e indicou o método mais adequado. In casu, a autora já fez uso de diversos medicamentos/tratamentos. Porém, atualmente lhe resta o uso do medicamento vindicado. Do contrário, a autora ficará sob grave risco e até com possibilidades de se submeter a colectomia, conforme asseverado em Laudo Médico anexado.

Anote-se que não se trata aqui de garantir cobertura irrestrita ao consumidor ou mesmo lhe conferir direitos além dos avençados, mas sim de garantir-lhe o tratamento necessário e cumprimento do próprio contrato, qual seja a proteção à saúde da autora.

Lado outro, verifica-se que a parte ré questiona a ausência de previsão contratual quanto ao fornecimento do medicamento à autora. Porém, se a enfermidade é coberta pelo plano de saúde, não pode a empresa ré estabelecer o tipo de tratamento a ser utilizado no combate da doença do demandante.

Sobre a possibilidade de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, os tribunais pátrios já se manifestaram, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE - CASSI. AUTORA IDOSA E PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOMINADO XELJANZ (CITRATO DE TOFACITINIBE) NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA E CONDENOU A RÉ EM DANOS MORAIS DE R$8.000.00. INCONFORMISMO DA RÉ QUE PRETENDE A REFORMA DO DECISUM. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS ENTIDADES QUE ADMINISTRAM PLANOS DE SAÚDE EM SISTEMA DE AUTOGESTÃO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.285.483/PB. COM EFEITO, NÃO OBSTANTE O CDC SEJA INAPLICÁVEL À ESPÉCIE, OS PLANOS DE SAÚDE GERIDOS POR AUTOGESTÃO DEVEM OBSERVAR OS DEVERES DE LEALDADE E DE INFORMAÇÃO, ÍNSITOS AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE TAMBÉM SÃO EXIGÍVEIS NOS CONTRATOS CIVIS EM GERAL, E NÃO APENAS NOS NEGÓCIOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. IN CASU, A CLÁUSULA LIMITATIVA QUE EXCLUI O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO PODERIA SER IMPOSTA À CONTRATANTE, POIS SEGUNDO O LAUDO MÉDICO, O FÁRMACO FOI INDICADO À PACIENTE EM RAZÃO DE SEU ESTADO CLÍNICO E TAMBÉM POR CONTA DA INTOLERÃNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº TJRJ 338 ("É ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI TRATAMENTO DOMICILIAR QUANDO ESSENCIAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A VIDA DO SEGURADO") E DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO AMPARO AO IDOSO - ART. 1º, III C/C ART. 230, AMBOS DA CR/88. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SÚMULA Nº 75 DESTE TJRJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINAR O RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E QUE OS HONORÁIROS SEJAM ARCADOS POR CADA PARTE COM SEU RESPECTIVO PATRONO. (TJ-RJ - APL: 00269075220158190011 RIO DE JANEIRO CABO FRIO 3 VARA CIVEL, Relator: INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 06/12/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017)

De outro giro, em sede de Agravo Interno, o Des. Relator reconsiderou sua decisão de suspensão dos efeitos da tutela concedida em 1º grau e deu provimento ao referido Agravo, determinando à operadora ré: *"o fornecimento do medicamento Tofacitinibe (Xeljans), nos moldes prescritos no laudo médico (ID n° 14216936), no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."*

Ademais, sobre a situação da autora - por ocasião da ausência do uso do medicamento – o médico assistente atestou que a autora "*evolui com vários episódios de diarreia, mais de 20 evacuações por dia, dor abdominal, sangramento intestinal e queda do estado geral* (ID n°69308723 - Pág. 1).

Acrescentou ainda o profissional que a demandante apresenta risco de complicações e de colectomia e, em razão da falha na resposta às medicações anteriormente utilizadas, prescreveu uso de tofacitinibe, mormente porque se trata da "única opção no momento disponível" (ID 69308723 - Pág. 1)

Com efeito, incumbe ao profissional de saúde decidir sobre o melhor tratamento ao paciente no combate à enfermidade, sobretudo observando o caso sob as lentes do princípio da dignidade da pessoa humana.

No mais, vale adicionar que a limitação no tratamento indicado pelo médico responsável é abusiva, vez que não se encontra em conformidade com as normas cogentes previstas na Lei n.º 8.078/90. Ora, se o(a) demandante firmou contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial/hospitalar, mostra-se abusiva cláusula que proíbe a realização de procedimentos indicados pelo médico de confiança, pois vai contra a natureza do próprio contrato, afrontando o art. 51, IV do CDC, que nulifica ajuste em contrato de adesão que coloque o consumidor em posição de desvantagem exagerada em relação ao fornecedor de produtos e serviços.

Ademais, a ausência de cobertura ao tratamento de saúde do autor, restringe direito fundamental e inerente à natureza do contrato, o qual deve ser regido, apenas, pela real necessidade do paciente diante do acometimento de doença, sendo unicamente indicador da necessidade do tratamento o posicionamento médico.

O art. 51, IV da Lei 8.078/90 é categórico quando expressa:

*"**Art. 51.** São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:*

(omissis)

***IV –** estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade;..."*

Prossegue, ainda, o § 1º do art. 51 do mencionado Diploma Legal:

*“**§ 1º** Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:*

(omissis)

***II –** restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;...”*

Assim, a existência de cláusula contratual que limite de forma abusiva e genérica o tratamento, contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta ao CDC (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90), colocando o segurado em situação de extrema desvantagem, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Anoto que, a despeito da licitude do plano de saúde quanto ao estabelecimento das moléstias cobertas, não se admite sua escolha do tipo de tratamento o qual deverá ser prescrito pelo médico especializado. No mais, a ausência de previsão expressa do procedimento em rol da ANS não obsta o fornecimento do tratamento por parte do plano de saúde.

Sobre a negativa fundada em rol da ANS, veja-se o que diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EVEROLIMUS PELO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA ROL DA ANS - ILICITUDE. O rol de procedimentos previsto em resoluções normativas da ANS não é taxativo. Ao contrário, elenca os procedimentos e medicamentos mínimos que devem ser colocados à disposição dos segurados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. (TJ-MG - AC: 10000200038628003 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Como se sabe, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS tem, dentre outras funções, a de regulamentar os procedimentos obrigatórios que devem ser cobertos pelos planos de saúde, todavia, seu poder de regulamentar não é ilimitado, mas complementar à lei dos planos de saúde. Isto quer dizer que a ela cabe publicar o rol mínimo de coberturas, não tendo poder para restringir ou limitar a responsabilidade das operadoras, que advém da lei e dos contratos celebrados com os consumidores. Neste sentido, confira-se entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E SER DE USO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO É inadmissível a negativa de fornecimento do medicamento "Tofacitinibe (Xeljanz)", o qual foi indicado pelo médico à beneficiária, para tratamento de retocolite ulcerativa grave com colite severa, sob fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS. (TJ-SP - AC: 10007358520208260011 SP 1000735-85.2020.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Destarte, resta evidente o dever de a parte ré arcar com a cobertura do tratamento do autor nos termos do(s) laudo(s) médico(s), sobretudo em decorrência da gravidade da síndrome a qual a autora é acometida.

Nesse contexto, não é dado à demandada discutir o tratamento indicado pelo médico responsável, a quem incumbe o diagnóstico e a prescrição da melhor terapêutica ao paciente, haja vista se tratar de doença não excluída da cobertura prevista. A negativa revela-se abusiva, portanto.

Além disso, os artigos 4°, inciso I e 47 do Código de Defesa do Consumidor, que são aplicáveis ao Plano de Saúde (Súmula 469 do STJ) são elucidativos ao dizer que as limitações devem ser sempre em favor do consumidor.

Portanto, a resistência da ré afronta o objetivo do contrato firmado, que é a preservação da vida. Tal conduta é abusiva, pois restringe direito inerente à natureza do contrato e frustra a realização de seu objetivo.

A propósito, assinala Nelson Nery Junior que “Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é óbvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor”.

No contrato de saúde o bem protegido é a vida. O consumidor só usará do contrato se tiver problemas de saúde. E a obrigação do segurador é de prestar todo tratamento necessário para que o segurado se recupere.

Assim, considerando que o Código de Defesa do Consumidor se constitui em norma cogente e de ordem social, que se sobrepõe à autonomia de vontade dos contratantes, tenho que a postura da parte demandada está em total desacordo com seus princípios, não podendo prevalecer em desfavor do consumidor, ora promovente.

Além do mais, repito, compete exclusivamente ao médico assistente definir qual o melhor tratamento para a melhora da qualidade de vida do paciente, não cabendo à operadora do plano de saúde escolher o modo de tratamento a ser utilizado, motivo pelo qual não se sustenta a restrição imposta pela parte demandada, de modo que é presente o dever de custear o tratamento, sendo flagrantemente abusiva conduta em sentido contrário.

Acima de qualquer outra consideração, não se pode perder de vista que a vida e a saúde das pessoas são bens jurídicos de valor inestimável e, por isso mesmo, tutelados pela Constituição Federal (artigos 196 e seguintes). Nesse sentido, o Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve oportunidade de proclamar:

A vida, dom maior, direito natural, não tem preço, mesmo para uma sociedade que perdeu o sentido da solidariedade, num mundo marcado pelo egoísmo, hedonista e insensível. Contudo, o reconhecimento do direito à sua manutenção não tem balizamento caritativo, pois carrega em si mesmo o selo da legitimidade constitucional e está ancorado em legislação obediente àquele comando" (Revista da Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina, ano 4, vol. 5, p. 321-322).

Sobreleva assinalar que, diante da notória incapacidade do Poder Público prover toda a população de uma assistência à saúde condigna, o setor privado, ao entrar em um nicho de mercado dos mais lucrativos, assume todos os riscos inerentes ao ramo dessa atividade econômica, pois, a toda evidência, de acordo com a velha máxima do sistema capitalista "quanto maior o lucro maior o risco".

Como assinala FERNÃO JUSTEN DE OLIVEIRA (Controle de Seguro-Saúde e o Regime do Código de Defesa do Consumidor, Revista de Direito Civil nº 78, p. 48):

"O sistema econômico adotado no Brasil supõe o lucro subordinado ao risco, à concorrência e ao respeito ao consumidor. Logo, a posição contrária às considerações acima parecem pretender a instituição de uma espécie de capitalismo sem risco e sem os ônus próprios da liberdade de iniciativa, absolutamente incompatível com o ordenamento constitucional".

No tema, veja-se o aresto, oriundo do extinto TAMG, abaixo transcrito:

CONSUMIDOR - UNIMED - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÁUSULA DE NÃO COBERTURA DE TRANSPLANTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NAS LEIS DE MERCADO - PECULIARIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS DO CASO. A saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem. Assim, ela não pode ser caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas. **O particular**

que presta uma atividade econômica correlacionada com serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, ou seja, os de prestar assistência médica e integral para os consumidores dos seus serviços. Esse entendimento não se sustenta somente no texto constitucional ou no Código de Defesa do Consumidor, mas, também, e, principalmente, na lei de mercado de que quanto maior é o lucro, maior também é o risco. Em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas do caso, deve o plano de saúde ressarcir o consumidor das despesas médico-hospitalares decorrentes de transplante de fígado" (Apel. Cível nº 264.003-9 - 12ª C.Cív. - Relª. Des. Maria Elza - DJMG 12.05.1999). (Grifei).

Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, **julgo procedentes** os pedidos aduzidos na inicial para**,** com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para condenar a demandada a **arcar** com a despesa do tratamento da autora relativamente ao fornecimento de medicamento, conforme indicado em Laudo Médico acostado aos autos.

Condeno a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Confirmo a tutela de urgência outrora proferida.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões (art. 1010 § 1º do NCPC). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009 §§ 1º e 2º do NCPC). Após, remetam-se os autos ao TJPE.

Registre-se, se for o caso, em sendo apresentado o recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (Art. 1.023, § 2º do NCPC).

Em caso de não interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, inexistindo requerimento das partes, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Jaboatão dos Guararapes, datado e assinado eletronicamente.

ADELSON FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ADELSON FREITAS DE ANDRADE JUNIOR
24/05/2021 11:30:03
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 81046546

21052411300039600000079366072

IMPRIMIR GERAR PDF